

1501009-88.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... não afasta a prática do tráfico. Em outras palavras, o usuário pode ser traficante.

Anoto por oportuno, que a alegação de dificuldades financeiras em nada favorece o réu e não configura a excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 24, do Código Penal).

Nesse sentido, a jurisprudência: "APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1501009-88.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON FERREIRA VIANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

ANDERSON FERREIRA VIANA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque segundo a denúncia, no dia 12 de julho de 2022, às 19h20min, na Rua Antônio Azevedo Marques, no. 1062, Jardim Toselar, nesta cidade e Comarca de Birigui, transportava 03 (três) tijolos e 02 (dois) tabletes de "maconha", pesando 3.069,85 gramas, e guardava 83 (oitenta e três) microtubos contendo "cocaína", pesando 50,05 gramas (peso líquido), 02 (duas) porções de pasta base de "cocaína", pesando 55,44 gramas (peso líquido).

O réu foi notificado e citado, apresentando defesa prévia às fls. 169. A denúncia foi recebida às fls. 171/173.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas

pela acusação, interrogando-se posteriormente o réu (fls. 188/189).

Em memoriais finais apresentados às fls. 209/216, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da acusação, com a consequente condenação nos termos da denúncia ofertada.

Requeru, ainda, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis processual e a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena.

A defesa a seu turno, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão e da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, a concessão direito de recorrer em liberdade e a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena. (fls. 199/206 e 219). É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução processual penal, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/14, auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, auto de depósito de fl. 24, autos de constatação prévia de entorpecentes de fls. 29/32, laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 78/86, laudos dos objetos apreendidos às fls. 87/92, bem como pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, restou devidamente induvidosa. Vejamos Destaca-se, inicialmente, que o réu confessou que guardava a droga para um terceiro, mas negou sua comercialização. Interrogado em juízo, Anderson alegou ter transportado e guardado o entorpecente por enfrentar dificuldades financeiras para sustentar os filhos, revelando receber a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais) para guardar os entorpecentes e os demais petrechos localizados pela polícia militar. Por fim, esclareceu que a droga e os petrechos estavam escondidos em um guarda roupas no seu quarto, revelando que a maconha localizada no veículo também seria guardava em sua residência.

Em seu depoimento, o policial Militar Aiglo Pereira Lopes narrou que no dia dos fatos estava em patrulhamento pelo bairro Toselar quando foi abordado por um transeunte, que preferiu ter sua identidade preservada por medo, o qual relatou que um indivíduo conduzindo um veículo modelo Fox, de cor preta, estava realizando a distribuição de entorpecentes pelo bairro.

Ao intensificar o patrulhamento, o depoente avistou o veículo com as características informadas estacionado defronte a residência de um indivíduo chamado Jonathan, já conhecido nos meios policiais pela traficância, sendo que ao notar a presença da viatura, Jonathan tentou ingressar no imóvel, enquanto Anderson tentou fugir com o veículo, mas foram abordados pelos policiais. Ao proceder à abordagem pessoal, com Jonathan foi localizada a quantia de R\$80,00 (oitenta reais) e na posse de Anderson foi localizado um aparelho celular, sendo que após ser questionado, o réu revelou a existência de drogas no interior do seu veículo.

Segundo o depoente, Anderson alegou que estava desempregado e recebia a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais) por mês para guardar a droga para um indivíduo, que não quis revelar a identidade, por medo. De acordo com o policial, Anderson informou a existência de mais entorpecentes em sua residência, para onde o depoente se dirigiu. Chegando ao imóvel, foram localizados 83 microtubos plásticos contendo cocaína, mais de 2000 microtubos plásticos vazios, 02 porções de pasta base de

cocaína, 02 balanças de precisão, um recipiente plástico contendo creatina e a quantia de R\$95,00 trocadas em notas diversas.

No mesmo sentido foi à declaração do policial Fernando Nunes Martins, acrescentando que Anderson confessou que estava guardando a droga para um indivíduo. Revelou ainda, que a creatina localizada é comumente utilizada pelos traficantes para aumentar a cocaína pura.

Pois bem. Conforme sobressai do conjunto probatório, não restam dúvidas que Anderson transportava e guardava as substâncias entorpecentes para fins mercantis. No caso vertente, a confissão judicial restou plenamente corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência. De fato, os policiais militares prestaram depoimentos uníssonos e fizeram suas declarações com convicção narrando os fatos de forma detalhada.

Referidos depoimentos, cabe ressaltar, têm valor probatório idêntico àquele prestado por outras pessoas, notadamente se em sintonia com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos. Há que se registrar que os policiais militares não tinham motivo para incriminarem injustamente o réu.

É ilustrativo o escólio jurisprudencial adiante colacionado, do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“PROVA – Testemunha – Policial – Revestindo-se de inquestionável eficácia o depoimento de servidores policiais, não se pode desqualificá-lo por emanar de agente estatal incumbido da repressão penal, circunstância que não afeta positiva ou negativamente o valor de sua palavra – Recurso não provido.” (Apelação Criminal n. 990.08.040006-1 – Limeira – 16ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Newton Neves – 10.02.09 – V.U. – Voto n. 6224).

Sendo ainda entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal: “É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.” (...) STJ - HC 76.557-RJ 2ª T., rel Carlos Velloso, 04.08.1998.

Saliente-se que, para fins de reconhecimento do delito, desnecessária a comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade e a forma de acondicionamento são suficientes para a conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente. Nesse entendimento, para a configuração do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, basta o ato de “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, não se exigindo o ato de mercancia.

No mesmo sentido é o entendimento Jurisprudencial: “Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda. Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de vendada substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de “trazer consigo”. (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014).

Ainda, importante mencionar as circunstâncias da apreensão, fundamentais a confirmar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. De fato, a diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), a grande quantidade

(3.069,85 gramas de maconha, 50,05 gramas de cocaína e 55,44 gramas de pasta base de cocaína), a forma de acondicionamento (03 tijolos, 02 tabletes, 83 microtubos plásticos e 02 porções), os petrechos comumente utilizados para a traficância (rolo de plástico filme, 02 balanças de precisão, 01 recipiente contendo creatina, 2500 microtubos plásticos vazios), a quantia de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) em notas diversas, confirmam a denúncia recebida pelos policiais militares e evidenciam o destino mercantil das substâncias entorpecentes.

Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, na obra "Legislação Penal Especial", ed. Atlas, 2ª edição, p.122, ensinam: "Ressalte-se, porém, que a comprovação elementar do tipo previsto no art. 16 - uso próprio - nem sempre é de fácil constatação, prevendo a própria lei, em seu art. 37, alguns critérios legais. Assim, para efeito de caracterização das condutas criminosas previstas na Lei nº 6.368/76, deverão ser analisados a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Deve, igualmente, ser levada em conta para efeito de tipificação do delito a forma de acondicionamento da substância entorpecente.".

Nesse raciocínio, incabível a desclassificação da imputação para o delito de porte de drogas para consumo próprio, pois as circunstâncias demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes, conforme acima mencionado.

Ademais, apesar de negar a comercialização dos entorpecentes, Anderson foi categórico ao revelar que guardava a droga e os petrechos para um indivíduo que não quis identificar e como forma de pagamento recebia a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais), de sorte que sua conduta se amolda perfeitamente ao tipo legal descrito na denúncia.

De mais a mais, ainda que se entendesse comprovado que o réu é usuário de drogas, certo é que tal circunstância não afasta a prática do tráfico. Em outras palavras, o usuário pode ser traficante.

Anoto por oportuno, que a alegação de dificuldades financeiras em nada favorece o réu e não configura a excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 24, do Código Penal).

Nesse sentido, a jurisprudência: "APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE TER AGIDO SOB ESTADO DE NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECONHECIMENTO - Impossibilidade: Bem provadas a autoria e a materialidade delitiva, não cabe reconhecer o alegado estado de necessidade porque precisava de dinheiro para o sustento de seu filho, submetido a intervenção cirúrgica, pois além de existirem outros meios para alcançar recursos econômicos, não há comprovação do quanto alegado. Recurso não provido." (TJ-SP - APL:32323720108260271 SP 0003232-37.2010.8.26.0271, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:31/05/2012, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2012).

Comprovadas, pois, a materialidade e autoria delitivas, um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo, pois à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e 42, da Lei de Drogas, a diversidade das drogas (maconha e cocaína), a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (03 (três) tijolos e 02 (dois) tabletes de "maconha", pesando 3.069,85 gramas, 83 (oitenta e três) microtubos contendo "cocaína", pesando 50,05 gramas e 02 (duas) porções de pasta base de "cocaína", pesando 55,44 gramas) recomendam a exasperação da pena-base. Dito isso, fixo a

pena-base em 1/4 acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes da pena. Entretanto, não se pode ignorar que o réu confessou a prática delitativa, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, perfazendo 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria da pena, não se ignora a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que, em tese, impediria a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

No entanto, a fim de se evitar o bis in idem, tendo em vista que a quantidade de drogas já foi utilizada na primeira fase de dosimetria para exasperar a pena-base, aplica-se o redutor em questão, tendo em vista que o réu é primário e não há provas robustas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Dito isso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias em que o delito foi praticado, levando-se em conta a primariedade e bons antecedentes do réu, diminuo a reprimenda em 1/6, atingindo 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, eis que o tráfico de entorpecentes se trata de ilícito penal equiparado aos crimes hediondos. Por identidade de razões, incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por incompatibilidade lógica.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por meio da presente ação penal para CONDENAR ANDERSON FERREIRA VIANA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, na modalidade "transportar" e "guardar" à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de provas de que o acusado possui boas condições financeiras.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Expeça-se mandado de prisão e recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

O réu não poderá recorrer em liberdade e deverá permanecer recolhido na prisão em que se encontra, porquanto persistem os motivos que deram ensejo à sua prisão cautelar. De mais a mais, tal medida também se mostra recomendável, à vista da gravidade do delito praticado. Por fim, o réu permaneceu preso durante todo o processo, persistindo os motivos de sua custódia cautelar.

Por fim, anoto que eventual detração da pena deverá ser deduzido perante o juízo da execução penal.

A incineração da droga já foi realizada (fl. 181), nada havendo a ser decidido. De outro lado, como o réu não fez prova da procedência lícita dos objetos e aparelho celular apreendido (fls. 18/19), razão pela qual se conclui que se tratam de instrumento e produto do tráfico de entorpecentes por ele praticado, pelo que decreto o perdimento em favor da União, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao "SENAD" quanto ao perdimento supradeterminado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Do mesmo modo, considerando que o veículo apreendido nos autos foi efetivamente utilizado para a prática do crime, declaro o seu perdimento em favor da União. Por

consequente, proceda-se à avaliação do bem.

Após, nos termos do provimento nº 1625/2009 do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo, decreto o perdimento do bem e defiro a realização da alienação judicial eletrônica de que se trata o artigo 689-A do Código de Processo Civil, designando, para tanto, a empresa privada LEILÕES JUDICIAIS SERRANO (administrativo@leiloesjudiciais.com.br), credenciada pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça.

A empresa responsável pela realização e divulgação dos leilões deverá ser comunicada pela zelosa Serventia por e-mail (juridico@leiloesjudiciais.com.br), com Pâmela Vanzin ou Jaqueline, ou por intermédio do 0800-707-9272.

Por fim, atento ao disposto no novel artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 90 (noventa) dias contados da publicação da sentença, torne os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente decisão, comunique-se a Justiça Eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

P.R.I.

Birigui, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA